

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제1절 소송의 개시>

I. 소의 의의

- 소란 원고가 피고를 상대로 법원에 대하여 특정한 심판을 구하는 신청을 의미한다. 이는 민사소송 절차를 개시시키는 유일한 수단이며, 법원의 판결을 이끌어내기 위한 기초가 된다. 소는 권리보호의 필요성이 인정되어야 하며, 소장이 법원에 접수됨으로써 그 절차가 시작된다. 현대 민사소송 체계에서 소는 사적 자치의 원칙에 따라 당사자의 자발적인 의사에 의해서만 개시된다는 처분권주의의 적용을 받는다.

II. 소의 종류

1. 청구의 성질·내용에 따른 분류

- 청구의 성질과 내용에 따라 소는 크게 이행의 소, 확인의 소, 형성의 소로 나뉜다. 이는 원고가 법원으로부터 어떠한 형태의 판결을 얻고자 하는가에 따른 구분이다.

(1) 이행의 소

- 이행의 소란 원고가 피고에 대하여 특정한 이행의무를 이행할 것을 구하는 소이다. 금전의 지급, 물건의 인도, 등기 절차의 이행 등이 대표적인 예이다. 이행의 소는 원칙적으로 현재 그 의무의 이행기가 도래한 경우에만 제기할 수 있는 현재의 이행의 소를 의미하나, 예외적으로 미리 청구할 필요가 있는 경우에는 이행기가 도래하지 않았더라도 장래의 이행의 소를 제기할 수 있다. 이행판결이 확정되면 그 판결 자체로 강제집행의 근거인 집행권원이 형성된다는 특징이 있다.

(2) 확인의 소

- 확인의 소란 특정한 법률관계의 존재 또는 부존재를 확정해 줄 것을 법원에 구하는 소이다. 확인의 소는 원칙적으로 현재의 법률관계를 대상으로 하여야 하며, 단순한 사실관계나 과거의 법률관계는 대상이 되지 않는다. 또한 원고의 법적 지위가 불안정하여 판결을 통해 이를 제거할 필요가 있는 확인의 이익이 인정되어야 한다. 확인판결은 법률관계를 공적으로 확정함으로써 분쟁을 종식시키는 기능을 하며, 별도의 강제집행 절차를 수반하지 않는다.

(3) 형성의 소

- 형성의 소란 새로운 법률관계를 발생시키거나, 기존의 법률관계를 변경, 소멸시킬 것을 구하는 소이다. 이는 당사자의 합의만으로는 목적을 달성할 수 없고 반드시 판결에 의해서만 법률적 변화가 일어나는 경우에 제기한다. 주주총회결의취소의 소, 공유물분할의 소, 재판상 이혼의 소 등이 이에 해당한다. 형성판결은 확정된 때로부터 즉시 대세적인 효력이 발생하여 법률관계를 형성시킨다. 법령에 특별한 규정이 있는 경우에만 허용된다는 법정주의 원칙이 적용된다.

2. 소제기의 모습에 따른 분류

- 소 제기가 어떤 방식으로 이루어지는가에 따른 분류이다.

(1) 독립의 소

- 하나의 소장에 하나의 청구를 담아 제기하는 일반적인 소의 형태를 말한다.

(2) 청구의 병합

- 소송 경제를 도모하고, 심리 중복을 피하기 위해 여러 개의 청구를 하나의 소송 절차에서 처리하는 것을 말한다.

(3) 공동소송

- 여러 당사자가 관련된 소송을 말한다.

(4) 반소

- 피고가 원고에 대응하여 같은 절차 내에서 제기하는 소를 말한다.

(5) 소송참가

- 소송 도중 제3자가 개입하는 것을 말한다.

3. 소제기의 시기에 따른 분류

- 소 제기가 소송 절차의 어느 단계에서 이루어지는가에 따른 분류이다.

(1) 최초의 소

- 소송 절차가 처음 시작될 때 제기되는 소를 의미한다.

(2) 청구의 변경

- 이미 소송이 계속 중인 상태에서 청구의 내용을 변경하거나 추가하는 소를 말한다.

(3) 부대항소

- 상소 절차에서 제기되는 소이다.

(4) 재심의 소

- 판결 확정 후 예외적으로 허용되는 소의 형태이다.

III. 결론

- 소의 개시는 당사자의 신청에 의해 국가의 재판권을 발동시키는 절차로서, 법치주의 하에서 권리 구제를 위한 핵심적인 통로이다. 이행, 확인, 형성의 소로 대표되는 내용적 분류는 각 분쟁의 특성에 맞는 적절한 보호 수단을 제공하며, 소제기의 모습과 시기에 따른 분류는 절차적 유연성을 부여한다. 법원은 원고가 제기한 소의 종류와 성질을 정확히 파악하여 그에 부합하는 소송요건과 본안 심리를 진행하여야 한다. 특히, 소제기 방식의 다양화는 복잡해지는 현대 사회의 분쟁을 일거에 해결할 수 있는 수단을 제공하는바, 이를 남용하지 않으면서도 실질적인 권리 구제가 이루어질 수 있도록 제도를 운영하는 지혜가 필요하다.